

1500899-78.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR DE SOUZA FILHO

Juiz de Direito: Dr. RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Vistos.

1. JAIR DE SOUZA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque, em 12 de abril de 2022, por volta das 01h24min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500899-78.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500899-78.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR DE SOUZA FILHO

Juiz de Direito: Dr. RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Vistos.

1. JAIR DE SOUZA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque, em 12 de abril de 2022, por volta das 01h24min, na Rua Aristides Belini, 587, Pestana, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo para entrega a consumo de terceiros 20 invólucros plásticos contendo "crack", 2 contendo cocaína e 18 contendo "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.2. Segundo consta na inicial acusatória, Policiais Militares avistaram o Denunciado e Marcos Bevenuto de Santana saindo de beco existente no local, que ao notarem a aproximação da viatura, demonstraram nervosismo, o que motivou a abordagem, que em revista pessoal encontraram os estupefacientes em posse do Denunciado e mais R\$ 114,00.

1.3. O recebimento da peça acusatória ocorreu em 26 de abril de 2022 (fls. 75), o Réu foi citado (fls. 135) e ofertou resposta à acusação (fls. 104/113), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 126). Naquela solenidade foram ouvidas duas testemunhas e o Denunciado interrogado (fls. 160/161).

1.4. Encerrada a instrução criminal, o Ilustre Representante do Ministério Público de São Paulo pediu a procedência da ação penal, agravando a pena intermediária em razão da reincidência e o afastamento da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33, da Lei de Drogas. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição, porque a quantidade de drogas encontradas indica que se destinavam ao uso, que o policial que revistou o Réu nada encontrou em sua posse, mencionaram filmagens da abordagem, mas nada foi juntado, nada justificaria a abordagem e que é comum em locais de venda de drogas o encontro de drogas deixadas pelos reais traficantes; em caso de condenação, requereu a fixação de regime semi-aberto para início de cumprimento de pena.

É o relatório. Decido.

2. A pretensão punitiva estatal é improcedente, porquanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas não foi devidamente comprovada, a despeito do auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 02/04, do auto de constatação de fls. 16 e do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 87/91. Tão pouco a autoria resta demonstrada, não se podendo olvidar que "o princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, preceitua, na sua acepção probatória, que cabe ao órgão acusatório o ônus de comprovar a ocorrência de todas as circunstâncias elementares do tipo penal atribuído ao acusado na incoativa, sob pena de tornar inviável a pretendida responsabilização criminal" (STF, (AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022)

2.2. Com efeito, Marcos Bevenuto de Santana, também abordado pelo Policiais Militares, no mesmo local indicado na exordial acusatória, qualificados às fls. 2, inquirido apenas em solo policial, disse que estava mesmo local em que localizadas as drogas discriminadas no auto de exibição e apreensão de fls. 16, com o intuito de adquirir entorpecentes para consumo próprio, "mas costuma pegar com outra pessoa que também não sabe identificar" (fls. 5).

2.3. Os depoimentos extrajudiciais dos Policiais Militares mencionados (fls. 6/7) não fazem qualquer menção a terem visualizado o Réu comercializando os entorpecentes localizados, nem que ele teria, mesmo informalmente, confessado a mercancia ilícita. De todo modo, é certo que "a percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos", o que leva à nulidade da "busca pessoal amparada na impressão de nervosismo do Acusado por parte dos agentes públicos" (REsp n. 1.961.459/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022), e, em Juízo, os Policiais Militares inquiridos nada acresceram de relevante à demonstração da autoria e materialidade delitivas.

2.4. De fato, a testemunha Vagner Alex Moraes, Policial Militar, afirmou que estava em patrulhamento, que ao adentrar no local dos fatos se deparou com dois indivíduos

parados na esquina, que o Acusado, ao perceber sua aproximação, foi em direção a um beco e tirou sua blusa colocando-a em cima de um carro próximo. Aduz que o local é conhecido como ponto de venda de drogas ilícitas, por isso, perguntou-o se tinha algo de ilícito, que lhe foi negado, mas localizou uma sacola na blusa retirada pelo Réu onde estavam os estupefacientes e o dinheiro, e que o Acusado afirmou na ocasião havia encontrado a sacola.

2.5. E a testemunha Ericks Barbosa de Sousa, também Policial Militar, narrou que no local dos fatos se deparou com um indivíduo que estava parado no meio da rua, logo em seguida, outro veio saindo do beco, ao tentar abordas os indivíduos, o Réu retirou a blusa que vestia e jogou em cima de um carro, na qual foi encontrada uma sacola com drogas e dinheiro. Expôs que não se recorda da cor da sacola, não conhecia o Acusado, começou a atuar recentemente na região e que quem revistou os indivíduos mencionados foi seu parceiro. Por fim, informou que estavam com câmeras em seus uniformes e que os fatos foram gravados.

2.6. Interrogado após ser informado do seu direitos constitucional ao silêncio, JAIR DE SOUZA FILHO disse que, na data indicada na exordial acusatória estava no local ali mencionado, haveria recebido de traficante cinco pedras de "crack", que havia as condicionado em maço de cigarros e não estavam em invólucro plástico, ao ser abordado, colocou o maço de cigarros e isqueiro em cima do carro, nenhuma droga foi encontrada em sua blusa, tão pouco trazia mais entorpecentes consigo, não comercializaria a droga encontrada, porque era destinada a seu uso. Afirma que a sacola foi encontrada no beco, que o Policial a entrou no local e voltou com a sacola, a qual não é sua e nem o dinheiro encontrado.

2.7. Sendo assim, não há demonstração de que as 20 (vinte) porções de "crack", 2 (duas) de cocaína e 18 (dezoito) de maconha, apreendidos com o Réu (fls. 16), seriam destinado ao comércio espúrio, nem de que o numerário localizado no momento da abordagem (R\$ 114,00) seria oriundo da traficância. Ao contrário, as citadas imagens capturadas pelas câmeras corporais em posse dos agentes policiais não foram trazidas aos autos, a quantidade de entorpecentes é pequena, não sendo irrazoável concluir que seriam destinados ao uso próprio, o que é corroborado pela informação de que JAIR é "morador de rua / andarilho" (fls. 11) e Marcos Bevenuto de Santana, quem poderia eventualmente esclarecer algo de relevante relacionado às alegações acusatórias, não foi arrolado como testemunha pelo Parquet.

2.8. De mais a mais, a nulidade da busca pessoal empreendida única e exclusivamente com fundamento no nervosismo do então averiguado, na medida que inexistia justa causa, ou seja, fundada suspeita a lastrear a medida, nos termos do parágrafo 2º do artigo 240 do Código de Processo Penal, impede, inclusive, a desclassificação da conduta típica imputada ao Réu para porte de estupefacientes para uso pessoal, prevista no artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006.

2.9. Sobre o tema, a jurisprudência das duas turmas que compõem a Colenda 3ª Seção do Tribunal da Cidadania aparenta convergência:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. No caso, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região, ocasião em que visualizaram o paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. Foi então realizada a sua abordagem em local público, e, na busca pessoal, foram localizadas em seu poder porções de drogas que o acusado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. 4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o

paciente absolvido da imputação constante na denúncia. 5. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente da imputação constante na denúncia. Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. (HC n. 722.175/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida (HC 680.214/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). 2. Na hipótese, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que o suspeito aparentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policiais (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivadas. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no HC n. 706.522/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

2.10. Acerca do necessária absolvição dos acusados na hipóteses em que a Acusação não se desincumbe de seu ônus probatório, destaco os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Inversão do julgado – Materialidade demonstrada – Autoria não comprovada – A diligência realizada pelos policiais militares não foi suficiente para imputar ao acusado a propriedade das drogas, ônus que cabia à acusação – Absolvição mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500256-80.2018.8.26.0633; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 01/02/2021)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Desclassificação da imputação para a de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28, L. 11.343/06). Cabimento. Quantidade irrisória, desacompanhada de outros apetrechos, que é insuficiente para caracterização do delito de tráfico, cujo ônus incumbe à acusação. Confissão informal isolada, não registrada nem corroborada em juízo pelo réu, que é incapaz de fundamentar a condenação. Precedentes do STJ. Acervo probatório insuficiente para concluir pela traficância. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500298-56.2020.8.26.0570; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Registro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022)

3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado JAIR DE SOUZA FILHO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, no dia 12 de abril de 2022, por volta das 01h24min, na Rua Aristides Belini, 587, Pestana, nesta Cidade e Comarca, com fulcro no artigo 386, cabeça, incisos II e V, do Código de Processo Penal.

3.2. Não havendo fumus comissi delicti a ensejar a permanência da prisão preventiva adrede decretada, revogo a cautelar extrema decretada pela r. decisão de fls.

48/52.

3.3. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Osasco, 22 de julho de 2022

RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA